

1508600-68.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1508600-

68.2021.8.26.0302-20220413_142653-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1508600-68.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001521

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330424/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21775758 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6983/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2330424 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARCIANO

Em 13 de abril de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. André Bergamin de Moura, Advogado constituído, neste ato, ora defendendo o acusado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARCIANO; o acusado referido; e as testemunhas Natalia Roberta de Carvalho, Aguinaldo Aparecido Pesuto e Caíque Augusto Canato, que prestaram seus depoimentos. O Ministério Público informou que desiste da oitiva de Caíque Canato, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARCIANO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"2, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022. (p. 146-147) e o réu foi citado (p. 177). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o

Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudos periciais. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e sustentou, em suma, que está sendo falsamente incriminado. Disse que tinha em sua posse apenas uma porção de cocaína, destinada ao seu consumo. Negou ter sido interrogado em solo policial ou admitido o tráfico aos policiais militares que o abordaram. A negativa do réu foi rechaçada pelas provas produzidas. O policial militar Aguinaldo relatou que estava em patrulhamento quando avistou o réu e sua companheira caminhando na via pública e, ao perceber a presença da viatura, ele passou a andar mais rapidamente e deixou a mulher para trás. O acusado foi abordado e em sua posse foi encontrado um estojo com "crack", maconha e cocaína, além de uma gilete, que o réu informou utilizar para fracionamento do "crack". Ele admitiu o uso e a venda de drogas. No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do PM Caique. A esposa do réu, Natalia, confirmou a abordagem do acusado e disse que viu o encontro apenas de uma porção de cocaína, cuja posse desconhecia. Informou que o réu é usuário de entorpecentes e estava trabalhando. A despeito da negativa do réu, as provas são suficientes para segura comprovação do crime que lhe foi imputado. Os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem, do encontro dos entorpecentes com o réu e da sua confissão informal e não há qualquer elemento seguro capaz de afastar as sobreditas versões. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). Ademais, em solo policial o réu admitiu a posse de maconha, cocaína e "crack" e a comercialização dos entorpecentes para o sustento do seu vício (pg.9). Naquela oportunidade, a sua companheira Natália confirmou ter visto o encontro de "uma bolsinha de cor roxa e no interior algumas drogas, não sabe exatamente quantas e quais eram elas" (pg. 8). Vê-se, pois, que, além da alegação de falsa incriminação por parte dos policiais militares não encontrar amparo em qualquer prova, o acolhimento da versão do réu implicaria reconhecer a existência de complô entre aqueles agentes e a polícia civil para falsa incriminação de um inocente, o que, evidentemente, não pode ser aceito. O fato do acusado não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(....)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767.

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Apesar da quantidade de drogas não ser grande, o réu levava 3 tipos diferentes de entorpecentes, além de uma gilete, que ele admitiu se destinar ao fracionamento do "crack". Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos seguros a infirmá-lo. E, ainda que ele seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvção - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Nessa toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade de parte do entorpecente apreendido - "crack" - substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto

no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase. Não se pode olvidar, ainda, que o réu praticou o delito durante cumprimento de pena em regime aberto. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo

publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal - art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Para ilustrar tal afirmativa, pode-se tomar por base o seguinte exemplo: um indivíduo condenado, por um crime qualquer, a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão - pena que imporia a fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 2º, do Código Penal) - e que tenha ficado preso preventivamente por 09 (nove) meses, terá a sua pena reduzida para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, podendo iniciar a sua pena no regime semiaberto após ter cumprido 09 (nove) meses no regime fechado (prisão preventiva). Por outro lado, se este mesmo indivíduo, condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por um crime qualquer, não tivesse ficado preso provisoriamente, estaria ele obrigado a iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado e só

poderia progredir para o regime semiaberto após ter cumprido 1/6 (um sexto) da sua punição, ou seja, seria exigido que ele cumprisse 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de regime fechado para que, comprovado seu bom comportamento carcerário, ele pudesse fazer jus ao regime prisional menos restritivo. A situação é ainda mais desproporcional no caso de condenações por crimes hediondos, onde a fração de pena cumprida para progressão de regime é maior do que a prevista na Lei de Execuções Penais, variando de 2/5 (dois quintos) a 3/5 (três quintos). Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARCIANO, qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 226 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, pois continuam presentes os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão, notadamente a necessidade de assegurar a ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARCIANO

CPF: 237.208.028-84, RG: 49890722, RJI: 170324370-21

Data De Nascimento: 05/09/1998

Filiação: mãe MARCIA REGINA DOS SANTOS MARCIANO

Residência: Rua Francisco Urbano, 179, celular:14-99876-6177 (Tim), Jardim Maria Luiza IV - CEP 17213-320, cel: 14-99876-6177, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.